

<제9장 무효등 확인소송.제6절 가구제>

I. 집행정지[행소법 제38조]

1. 준용 여부

- 집행정지란 처분등으로 인해 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위해 그 처분의 효력이나 집행을 잠정적으로 정지시키는 제도를 말한다. 행정소송법 제38조 제1항은 집행정지에 관한 규정인 제23조를 무효등 확인소송에 준용한다고 규정한다. 따라서 무효등 확인소송에서도 집행정지 신청이 가능하다.

2. 요건의 특수성

(1) 본안 청구의 계속 및 적법

- 집행정지 요건 중 본안 청구의 적법성은 무효확인소송의 특성상 그 확인이 용이하다는 점을 제외하고 취소소송과 동일하다.

(2) 회복하기 어려운 손해

- 처분의 집행으로 인해 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있어야 한다. 무효인 처분은 처음부터 효력이 없으므로 원칙적으로 집행력도 없으나, 외형상 처분이 존재하는 것처럼 집행이 강행되어 손해가 발생할 수 있다. 이 경우 회복하기 어려운 손해의 발생이 인정되어야 한다.

(3) 공공복리에 미치는 영향이 없을 것

- 집행정지가 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없어야 한다.

(4) 무효의 명백성(판례)

- 취소소송에서는 단순히 본안 청구가 이유 있음(승소 가능성)이 소명되어야 하지만, 무효확인소송의 경우 그 처분에 무효 사유가 명백하고 쉽게 소명되어야 집행정지가 허용된다는 것이 판례의 태도이다. 이는 무효인 처분은 효력이 없으므로 원칙적으로 집행정지가 필요하지 않다는 전제에서, 예외적으로 집행정지를 허용하는 기준을 높게 설정한 것이다.

II. 가처분

1. 문제의 소재

- 가처분이란 다툼 있는 권리 관계에 대해 본안 판결이 확정되기까지 법률 관계의 현상을 임시적으로 정하는 제도를 말한다. 행정소송법은 집행정지에 관한 규정만 두고 있을 뿐, 가처분에 관한 규정은 별도로 두고 있지 않다. 따라서 무효등 확인소송에서 가처분이 허용되는지 여부가 문제된다.

2. 판례의 태도

(1) 가처분 불허의 원칙

- 판례는 행정소송법상 가처분에 관한 명문 규정이 없을 뿐만 아니라, 집행정지 규정이 행정처분의 공정력이나 집행력을 정지시키는 특별한 가구제 수단이므로, 민사소송법상의 가처분 규정이 행정소송에 준용되지 않는다고 본다. 따라서 무효등 확인소송을 포함한 항고소송에서는 가처분이 원칙적으로 허용되지 않는다는 것이 확립된 판례의 태도이다.

(2) 예외적 인정론(학설)

- 학설 중에는 집행정지로는 구제할 수 없는 침익적인 비처분 행위나 부작위에 대한 확인소송 등에서는 국민의 권리 구제 실효성 확보를 위해 가처분을 예외적으로 인정해야 한다는 견해도 있으나, 판례는 이를 부정한다.

III. 결론

- 무효등 확인소송의 가구제 수단으로 집행정지는 행정소송법 규정에 따라 준용되어 인정된다. 다만, 무효확인소송의 본질상 그 처분의 무효가 명백히 소명되어야 한다는 점을 요건으로 한다. 반면, 가처분은 행정소송법상 명문 규정이 없으며 판례가 민사소송법상의 준용을 부정하는 태도를 취하고 있어 원칙적으로 허용되지 않는다. 이러한 가구제 수단의 제한적인 인정은 무효인 처분이 갖는 효력 부존재라는 특성과 행정법 관계의 안정성 유지 필요성을 조화시키려는 것이다.